

1501395-67.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito, área urbana em que reiteradamente são registradas prisões em flagrante por tráfico de drogas. Ocorre, no momento que manejava os ilícitos numa pena d'água na calçada, foi surpreendida pela aproximação de guardas municipais em patrulhamento. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501395-67.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

02244238/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2244238/2021 - 2º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÍNTIA FRANCIELE DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

\*

Aos 07 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel e a acusado(a)(s) CINTIA FRANCIELE DA SILVA. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) interrogatório da ré, pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, CÍNTIA FRANCIELE DA SILVA está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

DOS FATOS,

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de setembro de 2021, por volta de 23h50min, na Rua Pedro Grosse, n.º 345, Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, CÍNTIA FRANCIELE DA SILVA, qualificada e indiciada às fls. 04, 17/19, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 35 (trinta e cinco) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decigrama), e 25 (vinte e cinco) invólucros contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 2,5g (duas gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, CÍNTIA- que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito, área urbana em que reiteradamente são registradas prisões em flagrante por tráfico de drogas. Ocorre, no momento que manejava os ilícitos numa pena d'água na calçada, foi surpreendida pela aproximação de guardas municipais em patrulhamento.

Demonstrando nervosismo na brusca mudança de comportamento, foi abordada. Em sua posse nada foi localizado. No local em que mexia (Compartimento adornado com uma tampa de ferro fundido utilizado para controlar e restringir a pressão e o consumo de água nas unidades autônomas, na entrada da tubulação), foi encontrada uma bolsa contendo 35 (trinta e cinco) eppendorfs de cocaína e um pote com 25 (vinte e cinco) porções de crack (foto fls. 10).

Informalmente, CÍNTIA confirmou que vendia drogas no local e entregava os valores angariados a um indivíduo que, de tempo em tempo, passava no local. Na delegacia, porém, ficou silente (fls. 04). Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudos periciais de fls. 12/14 e de fls. 138/140).

Diante das circunstâncias, notadamente a condição pessoal da denunciada, o horário, local com grande incidência de registros policiais e a quantidade de droga incompatível com a mera destinação pessoal, é certo que a denunciado trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Pedro Carlos Girhão - Guarda Municipal - confirmou que em patrulhamento viu a ré mexendo em uma pena d'água. Abordou-a e encontrou na bolsa 35 porções de cocaína. O crack, 25 porções, estava em um pote. Ambas as drogas foram encontradas no mesmo lugar, na pena d'água. Não havia outras pessoas no local onde ela foi abordada. Apenas mais para baixo tinham outras pessoas. Conhecia a ré somente de vista. Ela confessou os fatos. Nunca a tinha abordado antes. Mas já a viu na mesma rua em outras oportunidades.

No mesmo sentido, Joel Vasconcelos de Lima - Guarda Municipal.

Interrogada, a ré negou os fatos. Disse que tinha ido comprar cigarro. O local é uma biqueira de consumo drogas. Viu os guardas encontrando as drogas. Estava apenas passando por perto, mas não mexeu na pena d'água.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: " A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela

expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuária de drogas, não afasta a possibilidade de que exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Da Dosimetria da Pena

Reincidência específica (0000857-05.2017.8.26.0599).

Pena acima do mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da

periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Cíntia Franciele da Silva foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 123-124), no dia 08 de setembro de 2021, por volta de 23h50, na rua Pedro Grosse, n.º 345, Vila Cristina, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Cíntia, supostamente, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 35 (trinta e cinco) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decígrama), e 25 (vinte e cinco) invólucros contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 2,5g (duas gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, Cíntia estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito, área urbana em que reiteradamente são registradas prisões em flagrante por tráfico de drogas. Ocorre, no momento que manejava os ilícitos numa pena d'água na calçada, foi surpreendida pela aproximação de guardas municipais em patrulhamento. Demonstrando nervosismo na brusca mudança de comportamento, foi abordada. Em sua posse nada foi localizado. No local em que mexia, foi encontrada uma bolsa contendo 35 (trinta e cinco) eppendorfs de cocaína e um pote com 25 (vinte e cinco) porções de crack (foto fls. 10). Informalmente, Cíntia confirmou que vendia drogas no local e entregava os valores angariados a um indivíduo que, de tempo em tempo, passava no local.

Interrogado em solo policial, a ré exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 04).

Pedro Carlos Girhã, guarda civil, narrou que "estava em patrulhamento ostensivo de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas. Em determinado momento, avistou uma mulher abaixada mexendo numa pena-d'água na calçada. Ocorre que, ao notar a aproximação da viatura, a mulher em comento, ora indiciada, levantou-se rapidamente de maneira suspeita, motivo pelo qual resolver realizar abordagem para averiguação. Na posse da indiciada nada havia. Ocorre que, na pena-d'água acima mencionada, foi localizada uma bolsa dentro da qual havia trinta e cinco porções de cocaína e um pote, dentro do qual havia vinte e cinco porções de crack. De maneira informal, a indiciada confessou que estava no local realizando a traficância, mas não transmitiu detalhes sobre o fato, somente que entrega o dinheiro da venda para um desconhecido que passa pelo local de tempos em tempos" (fls. 02).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Felipe Vieira Alves (fls. 03).

Às fls. 31-37, juntadas certidões de objeto e pé e folha de antecedentes que indicam a reincidência (autos n.º 0000857-05.2017.8.26.0599 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 30/10/2017, pena julgada extinta em

12/02/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08-09, fotografia de fls. 10, laudo pericial de constatação de fls. 12-14 e laudo de exame definitivo de fls. 138-140.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, Pedro Carlos Girhã, guarda municipal. Estavam passando pelo local dos fatos e viram a acusada mexendo em uma pena d'água. Ela se assustou ao ver os guardas. Abordada, com ela nada foi localizado. Na pena d'água, localizou-se uma bolsinha com 35 porções de cocaína e havia, em um potinho, 25 porções de crack. A acusada teria confessado a traficância. Vendia a 10 reais a porção de cocaína e 5 reais a porção de crack. O dinheiro teria sido entregue ao responsável pela droga. No local em que estava, somente ela estava. Mais para baixo, havia outras pessoas. Conhecia Cinthia somente de vista. Nunca a tinha abordado, mas já a tinha visto na mesma rua. Sabe que ela reside a aproximadamente 500 metros do local. Disse que a acusada estava abaixada e parada. Pena d'água é um cano.

b) Em seguida, ouvido o guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda. Não conhecia a ré.

c) Por fim, foi interrogada a ré Cíntia Franciele da Silva. Relatou que foi comprar cigarro na rua de cima de sua casa. Na rua, realmente há tráfico. No bairro em que mora há mesmo muitas biqueiras. Estava passando pelo local e foi abordada. Os policiais estavam parando mais pessoas. Foi parada, mas não tinha nada consigo. Viu os policiais achando a droga na pena d'água, mas não era sua. A sua filha estava vindo ao seu encontro, estava aguardando-a. conhece o guarda Gihirão, não tem nada contra ele. Havia outras pessoas sendo abordadas, mas foram liberadas.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  
Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, logo após a visualização da imputada, eles efetuaram a abordagem imediatamente por considerarem que o seu comportamento denotava nervosismo; a averiguada, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver "fundada suspeita" (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as

guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da atuação da guarda, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal da ré (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydney de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a

responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há a reincidência permitindo o aumento da pena em 1/6. No mais, tendo em vista que, pelo relato dos guardas, a acusada confessou a traficância, deve-se também computar a atenuante da confissão, compensando-a com a reincidência.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação de regime diverso do fechado.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado à acusada o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

CÍNTIA FRANCIELE DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de setembro de 2021, por volta de 23h50, na Rua Pedro Grosse, nº 345, Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 35 (trinta e cinco) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decígrama), e 25 (vinte e cinco) invólucros contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 2,5g (duas gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Cíntia - que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito, área urbana em que reiteradamente são registradas prisões em flagrante por tráfico de drogas.

Ocorre, no momento que manejava os ilícitos numa pena d'água na calçada, foi surpreendida pela aproximação de guardas municipais em patrulhamento. Demonstrando nervosismo na brusca mudança de comportamento, foi abordada.

Em sua posse nada foi localizado. No local em que mexia, foi encontrada uma bolsa contendo 35 (trinta e cinco) eppendorfs de cocaína e um pote com 25 (vinte e cinco) porções de crack (foto fls. 10).

Informalmente, Cíntia confirmou que vendia drogas no local e entregava os valores angariados a um indivíduo que, de tempo em tempo, passava no local. Na delegacia, porém, ficou silente (fls. 04).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial fls. 12/14).

Diante das circunstâncias, notadamente a condição pessoal da ré, o horário, local com grande incidência de registros policiais e a quantidade de droga incompatível com a mera destinação pessoal, é certo que a ré trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 123/124), sendo determinada a notificação da ré para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 125/126). Notificada (fls. 132), a ré apresentou defesa preliminar, na qual informou que não há questões preliminares conhecidas e as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 136/137).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 141/143). A ré foi citada (fls. 168).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns (fls. 173), sendo a ré interrogada.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante da ré.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que avistaram a ré em local conhecido por intenso tráfico de drogas e visualizaram-na agachada, mexendo em uma pena d'água. A ré, por seu turno, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e, por isso, efetuaram a abordagem, quando as drogas foram encontradas exatamente no local em que os guardas tinham visto a ré mexendo.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, a ré foi abordada quando guardava entorpecente, havendo flagrante de crime permanente, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexiste ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer

que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - Resp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuaram sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a

saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCr: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morenghi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade - Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis - Réus em situação de flagrância, cuja prisão pode ser efetuada por qualquer pessoa - Artigo 301 do CPP - Preliminar rejeitada -

Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder dos acusados - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Penas-base fixadas em seus patamares mínimos - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição mantida - Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante - Hipótese de coautoria - Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas - Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes - Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

## II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

### 1) Da materialidade

A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, na fotografia de fls. 10, no laudo de constatação de fls. 12/14, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 138/140, segundo o qual foi detectada a presença da substância cocaína, no material apreendido.

### 2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos. Vejamos.

Na fase investigativa, a ré permaneceu silente (fls. 04).

Em Juízo, a ré alegou que estava indo comprar cigarro. No local é uma biqueira mesmo. Foi abordada e os policiais encontraram a droga no cano da água. No local onde mora, existem muitas biqueiras. Passava perto da pena d'água, mas não mexeu nela. A droga não lhe pertencia. Só tinha dinheiro para comprar o cigarro. Estava esperando a filha, quando foi abordada. Não era ela quem vendia drogas no local. na época, não fazia uso de drogas. estava recém-operada. Conhece o guarda Gihirão, porquês eu filho já deu bastante trabalho, mas nada tem contra ele. O local fica perto da sua casa. onde mora, em todo lugar tem tráfico de drogas. acha que Gihirão não tem nada contra ela. Outras pessoas foram abordadas também, mas todos foram liberados.

A autoria foi comprovada pelas demais provas existentes nos autos. Vejamos.

O guarda municipal Pedro Carlos Gihirão asseverou que estavam em patrulhamento, em local já bem conhecido como ponto de venda de drogas, quando verificaram a ré mexendo numa pena de água. Ela se assustou quando viu a viatura e, por isso fizeram a abordagem. Na pena d'água, encontraram uma bolsinha com 35 porções de cocaína. Havia também 25 porções de crack, num pote, na mesma pena d'água. Indagada, a ré disse que estava na venda de drogas no local e o dinheiro arrecadado já tinha sido recolhido por terceira pessoa. No local onde a ré estava, só havia ela. Mais para

baixo, havia outras pessoas. Conhecia a ré de vista, mas nunca a havia abordado. Já a tinha visto outras vezes, na mesma rua. A ré reside na região, mas não na mesma rua, cerca de 500 metros de distância do local da abordagem. A pena d'água é um cano da calçada. A ré estava agachada, mexendo no cano (fls. 173).

No mesmo sentido, o depoimento do também guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima, segundo o qual estavam em patrulhamento em local conhecido por intenso tráfico de drogas, quando avistaram a ré agachando, mexendo numa pena d'água. Na intenção de esconder o que estava fazendo, ela se levantou rapidamente. Isso chamou a atenção da equipe e abordaram a ré. No local onde ela estava abaixada, encontraram crack e cocaína. Questionada, a ré falou que estava vendendo as drogas e que o dinheiro da venda já tinha sido entregue ao responsável pela droga. O crack estava num potinho e a cocaína numa bolsinha. Não conhecia a ré. No local, só estava a ré, sozinha (fls. 173).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento da ré com a droga apreendida.

A ré, em solo policial, nada disse sobre os fatos. Perante o Juízo, negou a prática delitiva, dizendo eu apenas passava pelo local e foi abordada. Negou que tivesse mexido na pena d'água.

Os guardas municipais narraram que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando visualizaram a ré agachada em uma pena d'água, na calçada e sozinha. Depois que percebeu a aproximação da viatura, a ré se levantou rapidamente e, por isso, foi abordada. Com a ré, nada havia de ilícito, no entanto, na pena-d'água em que ela foi avistada mexendo, os guardas civis encontraram uma bolsa, contendo 35 porções de cocaína, e um pote, no qual havia 25 porções de crack. Informalmente, a ré confessou que estava no local na prática do tráfico de drogas e que constantemente uma pessoa passava pelo local para pegar o dinheiro.

Nesse sentido, existem duas versões sobre o mesmo fato: a da ré, que nega qualquer relação com a droga apreendida, e a dos guardas civis que visualizaram-na mexendo na pena-d'água onde as drogas foram encontradas.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Em primeiro lugar, o local onde a ré estava era conhecido como ponto de venda de drogas e, além disso, ela foi vista agachada exatamente no local onde a droga estava escondida.

Ora, se a droga foi localizada exatamente no local onde a ré foi vista agachada e mexendo, é porque ela tinha relação com o entorpecente.

De outro lado, a palavra de guardas municipais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória